

1500220-86.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... está acontecendo algum crime, não só por tráfico mas até mesmo pela criança, se é dela, se não é, de onde veio essa criança, porém foi constatado o tráfico."

Inquirida acerca dos motivos para a realização da busca domiciliar, a testemunha respondeu: "O que chamou atenção foi ela estar nesse horário do lado de fora, aparentemente aguardando alguém, com as vestimentas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500220-86.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 22 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500220-86.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELISABETH SANTOS DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

ELISABETH SANTOS DE SOUZA e WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES, qualificados nos autos (fls. 14 e 222), foram denunciados pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 04 de março de 2021, por volta das 06horas, na rua Pará, nº 230, Jardim Itapura, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, juntos e mediante unidade de propósitos, traziam consigo e

transportavam, utilizando-se de transporte público e visando o fornecimento a terceiros, 1.035,25 gramas de "cocaína" em porção, sem licença da autoridade competente e em desacordo com disposição regulamentar, tratando-se de substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, classificada como droga alucinógena e despersonalizante.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 05 e 06) e de interrogatório (fls. 07), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 12/13), fotografias da substância entorpecente apreendida (fls. 19/20) e da denunciada (fls. 21/22), Pesquisa Prodesp (fls. 29/41), cópia do documento de identificação civil da ré - RG (fls. 42), Laudo de Constatação (fls. 43/45), Pesquisa Sivec (fls. 46/47), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 48/49 e 64/69) e Folha de Antecedentes (fls. 50/63).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 83/85), e da Defesa (fls. 87/96), houve o relaxamento da prisão em flagrante em relação ao acusado Wellington, e a conversão em prisão preventiva no que tange à acusada Elisabeth (decisão a fls. 98/105), com a expedição dos respectivos mandado de prisão (fls. 106/107) e alvará de soltura (fls. 108/109), devidamente cumprido (fls. 114/115).

Na sequência, a denunciada Elisabeth apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 125/140, acompanhado dos documentos de fls. 142/148), que, após a juntada de ofício enviado pela Penitenciária (fls. 155/161), e a manifestação do Ministério Público (fls. 166), restou deferido, com a concessão do benefício da liberdade provisória e a imposição de medidas cautelares (fls. 167), sendo expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 170/172), devidamente cumprido (fls. 175/178), sobrevivendo aos autos, na sequência, guia de depósito judicial (fls. 180 - R\$15,00), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 184/186), Laudo Pericial atinente ao aparelho celular apreendido (fls. 187/196), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2061766-41.2021.090500 - fls. 197/199), RG criminal (fls. 218), e cópia de Boletim de Ocorrência referente a fuga do denunciado do Estabelecimento prisional (fls. 219/220).

Oferecida a denúncia (fls. 02/03), os réus foram notificados (certidões a fls. 249 e 271) e, por meio de Defensor Público, o denunciado Wellington ofertou resposta (fls. 257/261), bem como, a acusada Elisabeth, por meio de Defensor constituído (procuração a fls. 141), ofertou resposta (fls. 275/279), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 286), sido recebida em 28.02.2022 (fls. 287).

Após a citação dos acusados (fls. 305 e 315), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 344/345), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de uma testemunha e aos atos de interrogatório.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 347/353), pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena em relação à ré Elisabeth, pela fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da mesma lei, pelo estabelecimento do regime inicial fechado, opondo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Quanto à dosimetria da pena do réu Wellington, requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, observando ainda a presença da circunstância judicial dos maus antecedentes, a incidência da circunstância agravante da reincidência, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Antitóxicos, terminando por opor-se à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, e por defender o estabelecimento do regime inicial

fechado.

De seu turno, a Defesa do réu Wellington, em memoriais finais (fls. 362/390), pleiteou, inicialmente, a nulidade da busca domiciliar pela ausência de mandado e de notícia de fato inespecífico, com o desentranhamento dos documentos da apreensão dos objetos e substâncias, e a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, e, no mérito, aduzindo insuficiência de provas, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII do CPP e, em caso de condenação, pela fixação da pena base no mínimo legal, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da mesma lei, terminando por defender o estabelecimento do regime menos gravoso, com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Defesa da ré Elisabeth, em memoriais finais (fls. 395/402), aduzindo as teses de nulidade da busca e apreensão realizada na residência da acusada, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, e insuficiência de provas, requereu a absolvição da ré, nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caso de condenação, pleiteou a incidência da circunstância atenuante atinente a confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, e o estabelecimento do regime inicial aberto.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 05 e 06) e de interrogatório (fls. 07), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 12/13), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 184/186), Laudo Pericial atinente ao aparelho celular apreendido (fls. 187/196), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2061766-41.2021.090500 - fls. 197/199), cópia de Boletim de Ocorrência referente a fuga do denunciado do Estabelecimento prisional (fls. 219/220), e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 344/345).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 184/186), tanto a natureza entorpecente da substância apreendida em posse da ré (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 12/13), uma vez que "...DETECTADA a presença da substância COCAÍNA", quanto a sua quantidade (item 1: "Massa Líquida: 996,26 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia a ambos os réus e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 06), a testemunha Patrício Fernando de Souza, policial militar, em Juízo (fls. 344/345), narrou que estava em patrulhamento pela avenida Brasil, área central, próximo à

rodoviária de Presidente Prudente, quando chegou um taxista informando as características de uma mulher, a qual estaria muito nervosa, afoita, o que teria lhe chamado a atenção, e que a teria deixado próximo à rua Pará, Vila Marcondes, relatando, ainda, que estaria ela com uma mochila preta, vestimentas pretas, e uma criança. Assim, em patrulhamento com vistas à localização da referida mulher, a avistou em via pública, na rua Pará, nº 230, sendo realizado, de imediato, a sua abordagem e, feito contato com a sogra dela, e obtida autorização para ingresso no imóvel, em seu interior, localizou, sobre a cama, a mochila indicada, com aproximadamente um quilograma de "cocaína", aparelho celular e quinze reais em dinheiro, tendo a ré, ao ser indagada, informado que tinha acabado de chegar de Ribeirão Preto, onde teria buscado o entorpecente e estaria trazendo para Presidente Prudente, afirmando, ainda, ter pegado a droga com desconhecido, e que, a mando de seu irmão, que estava preso na penitenciária de Valparaíso, entregaria o entorpecente a outro desconhecido.

Explicou ainda que a ré, embora tenha alegado não ser usuária de drogas, disse que receberia 50 (cinquenta) gramas da mesma droga para poder fazer esse transporte, e que, após ser conduzida até a Delegacia e informar o nome completo do irmão, foi constatado pela Autoridade que, realmente, ele estaria preso na penitenciária de Valparaíso.

Em respostas as perguntas, alegou a testemunha que não teve acesso ao celular da ré, não sendo por ela comentado, na oportunidade, o nome de "To" e "magrelo".

Questionada se o taxista chegou a dar algum detalhe acerca das suspeitas que havia com relação a ré, a testemunha respondeu: "Não, só a questão do nervosismo dela, de querer chegar muito rápido, com pressa, o que chamou atenção foi a criança, a gente foi atrás a abordagem não até mesmo pela droga, mas até mesmo pela criança, para saber se realmente está acontecendo algum crime, não só por tráfico mas até mesmo pela criança, se é dela, se não é, de onde veio essa criança, porém foi constatado o tráfico."

Inquirida acerca dos motivos para a realização da busca domiciliar, a testemunha respondeu: "O que chamou atenção foi ela estar nesse horário do lado de fora, aparentemente aguardando alguém, com as vestimentas e características que foram passadas para a gente, roupas pretas, e aí então faltava uma criança e uma mochila, a gente precisava saber onde que estava essa criança, e essa mochila."

No mesmo trilhar foi o depoimento prestado em Delegacia pelo policial militar Gabriel Lima Pereira (fls. 05).

De sua vez, a ré Elisabeth, alterando a versão dos fatos inicialmente apresentada em Delegacia (fls. 07), ocasião em que alegou que: "não levaria a droga para o irmão na visita da penitenciária, que apenas ficou de trazê-la hoje até a casa de sua sogra, onde alguém pegaria a droga, venderia, e levaria o dinheiro para o irmão, que está na Penitenciária de Valparaíso", em Juízo (fls. 344/345), sustentou que seu irmão não tem nenhuma participação com o ocorrido, afirmando que estava nervosa naquele dia, e que, por ser usuária à época, foi buscar drogas para usar em Ribeirão Preto e, quando retornou a Presidente Prudente, pegou um taxi até a casa de sua ex-sogra e, quando estava no interior da residência, a Polícia invadiu e realizou a revista, sendo encontrada a droga na bolsa, ocasião em que negou ser usuária, pois ficou nervosa e com vergonha.

Questionada, disse a ré não saber para quem iria entregar a droga e que receberia, em contrapartida, uma porção de "maconha", e, quanto ao envolvimento de seu irmão, afirmou ter sido um erro, aduzindo que, por achar que não daria problema, ficou nervosa na hora e acabou falando que era ele.

Confirmou a ré, ainda, que a pessoa de nome "To" seria sua irmã e, quanto as

conversas retratadas a fls. 191, disse que, na verdade, foi para Ribeirão Preto, tendo dito à irmã que iria ao Paraguai para buscar roupa, pois não queria que ninguém soubesse.

Negou ter conversado com o irmão por telefone, e, quanto ao diálogo com o contato nominado "irmão", na qual teria dito, "bom pode ficar tranquilo, que se um uber não puder me pegar, eu pego um taxi, que fica bem de frente aonde eu vou descer e já desço, mas aí eu não vou descer para a casa da mãe, vou descer para a minha sogra tá, aí depois você tem que ver com quem que eu vou deixar essa roupa ta bom" (fls. 191), aduziu que tal pessoa não era seu irmão, mas sim o indivíduo para quem foi buscar a droga, tendo salvado seu contato como "irmão", pois não sabia seu nome, e, quanto à expressão mãe utilizada na conversa, alegou que, por estar nervosa, acabou digitando errado.

Por sua vez, o réu Wellington dos Santos Rodrigues, ao ser interrogado em Juízo (fls. 344/345), negou participação na prática delitiva, afirmando que estava preso na cadeia e já não mexia mais com nada de errado. Confirmou que "To" seria sua irmã de nome Ariadne, e negou ter conversado por telefone com a irmã no dia dos fatos, sustentando não saber mexer em telefone e jamais ter sido visitado na cadeia por sua irmã.

Nesse aspecto, e diante negativa apresentada pelo réu Wellington e a versão contraditória apresentada pela acusada Elisabeth, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas (policiais militares), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputarem a prática do crime aos réus, de modo que seus relatos, não só pela honrosa função pública que exercem, devem ser sopesados e prestigiados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os

mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.” (negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Ademais, é de se ver que, apesar das levianas arguições da ré em Juízo (Termo a fls. 344/345), as conversas presentes no celular consigo apreendido, obtidas por meio da perícia realizada (Laudo Pericial a fls. 187/196), não deixam dúvidas de que esta estava a realizar o transporte da droga a mando do corréu Wellington, cabendo destacar que, um dia antes da prisão efetuada, a ré se comunicou com sua irmã, conhecida como “To”, afirmando que estaria num hotel no Paraguai esperando para ir embora (“ex vi” fls. 191). De igual maneira, também um dia antes de sua prisão, a denunciada conversou com seu irmão (corréu Wellington) sobre o momento de sua chegada em Presidente Prudente com a droga (“Ta bom. Mas não, pode ficar tranquilo que se um Uber não puder me pegar eu pego um rádio taxi que fica bem de frente onde eu vou descer, e já desço. Mas aí eu não vou descer pra casa da mãe, eu vou descer pra minha sogra, ta? Aí depois, aí cê tem que ver com quem que eu vou deixar... deixar essa roupa. Tá bom?” – “ex vi” fls. 191). Ainda por meio dos registros capturados, percebe-se que Wellington, ainda no dia 04/03/2021 (data dos fatos), após a meia noite e, portanto, antes da chegada dela nesta cidade de Presidente Prudente, questiona a irmã perguntando se ela conseguiu falar com a pessoa de “magrelo”.

Aliás, a evidenciar o conluio dos denunciados, cumpre observar que, logo após a abordagem e prisão em flagrante da ré, o que, segundo o Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), se deu entre 06/07 horas da manhã do dia 04.03.2021, nos termos do Boletim de Ocorrência carreado (fls. 219/220), especificamente as 10h40min, o réu, que encontrava-se cumprindo pena no CDP de Valparaíso, fugiu do local, certamente por ter tomado conhecimento do que tinha ocorrido com a ré, sua irmã.

No mais, não merece prosperar o pedido deduzido pela nobre Defesa, voltado ao reconhecimento da tese de nulidade da busca domiciliar, uma vez que, além de ter existido, conforme esclarecido em Juízo pela testemunha policial, e, diga-se, não desmerecido, a prévia solicitação e autorização da proprietária do imóvel (ex-sogra da ré) para ingresso na residência, a ação policial justificou-se plenamente face a apreensão da grande quantidade de entorpecente – quase um kilo de “cocaína” -, bem como, às circunstâncias que permearam o presente delito, já que, diante das suspeitas/informações recebidas do taxista, existiam fundadas razões da ré estar praticando algum ilícito, o que, com a entrada no imóvel, se confirmou com a apreensão do entorpecente.

Aliás, o crime de tráfico de entorpecentes é permanente, possibilitando, assim, a entrada no domicílio do indivíduo enquanto perdurar o estado de flagrância.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial nº 603.616/R0, julgado sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que, havendo “elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, é possível excepcionar a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar:

[...] 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. [...]

(STF; Tribunal Pleno; RE 603.616/R0; Relator: MINISTRO GILMAR MENDES; j. 05.11.2015).

Por certo, “fundadas razões” e “justa causa” são conceitos jurídicos indeterminados, de modo que a leitura do voto do Ministro Relator é de grande valia para compreender quais fatos caracterizam a “justa causa”:

[...] A busca foi realizada sem mandado judicial. No entanto, havia fundadas razões para suspeitar que o recorrente estava em situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas. O acórdão recorrido assenta que o investigado e Reinaldo Campanha eram suspeitos de transportar drogas. Reinaldo dirigia caminhão de propriedade do recorrente. A polícia já havia monitorado encontros de ambos. Em 20.4.2007, Reinaldo partiu da casa do recorrente Paulo Roberto dirigindo caminhão que, posteriormente, foi interceptado. Inspeccionado o veículo, foram localizados 23,421 kg (vinte e três quilos, quatrocentos e vinte e um gramas) de cocaína. Após a prisão, Reinaldo teria confirmado receber a droga de Paulo Roberto. Na sequência, os policiais foram à residência de Paulo Roberto e ingressaram na casa e em seu terreno sem autorização. Ao revistarem o veículo estacionado na garagem, localizaram os 8,542 kg (oito quilos, quinhentos e quarenta e dois gramas) de cocaína adicionais. O ingresso forçado na casa estava amparado no acompanhamento prévio e nas declarações do flagrado Reinaldo, elementos suficientes para indicar fundadas razões de que Paulo Roberto estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas. [...]

Pertinente transcrever, ainda, a manifestação do Ministro Celso de Mello, durante os debates:

É fundamental que exista causa provável, cuja ocorrência legitimará o ingresso de terceiros em residência alheia, ainda que “invito domino”, desde que, por óbvio, registre-se qualquer das situações excepcionais a que alude o inciso XI do art. 5º da Constituição.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação de ambos os réus.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

ELISABETH SANTOS DE SOUZA

Em consonância com os artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que, apesar da ré não ostentar qualquer condenação criminal (Folha de Antecedentes – fls. 46/47; Certidão de Distribuições Criminais – fls. 48/49), apresenta culpabilidade acentuada (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta), pois transportava consigo significativa quantidade de droga ilícita – quase um kilo de “cocaína” -, que, além de proporcionar lucro vultuoso ao grupo criminoso articulador, elevando o seu poder econômico para a prática de outros crimes, fomenta a prática de outros delitos patrimoniais, notadamente os mais graves, causando, ainda, danos irreparáveis para diversas famílias, vítimas do vício nefasto proporcionado pela disseminação descontrolada de entorpecentes ilícitos.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira da ré, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que a ré, na essência, tanto em Delegacia (fls. 07), quanto em Juízo (fls.344/345), confessou espontaneamente a prática do crime imputado (art. 65, III, "d", CP), razão pela qual atenuam-se as penas na fração de 1/6 (um sexto), contudo, sendo incabível a atenuação das sanções para patamares inferiores aos mínimos nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ), permanecem as penas nos níveis iniciais, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento capitulada no art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, haja vista o tráfico ter, como bem evidenciado nos autos, ocorrido em transporte público, elevam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

Imperioso, por outro lado, o reconhecimento da causa de diminuição de pena capitulada no artigo 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, posto que a ré não ostenta qualquer condenação criminal e não há prova de que integre organização criminosa, tampouco de que se dedique a atividades ilícitas.

De outro vértice, não é o caso de se aplicar a fração máxima de redução, haja vista, além do efeito deletério, a significativa quantidade do entorpecente apreendido ("cocaína").

Nesse sentido:

"Na falta de indicação pelo legislador de balizas para o quantum de redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição do patamar de redução ou, até mesmo, para impedir a aplicação da minorante quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes".
(STJ; HC 364113/SP; Quinta Turma; Ministro Ribeiro Dantas; j. 04.10.2016)."

Nesse raciocínio, tais elementos determinam a redução intermediária da pena em 1/2 (metade), passando-a para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao regime prisional, tendo em vista o quantum da pena imposta e a recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, de relatoria do i. Ministro Rogerio Schietti Cruz (item 21.4.: "Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena"), imperioso, observado os parâmetros dispostos no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o estabelecimento do regime aberto.

Descabida, de outro lado, implicando alteração de entendimento pessoal pretérito, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, simplesmente porque tal benefício, à vista das circunstâncias do caso e, especialmente, da nocividade da conduta praticada, não se apresenta como medida suficiente e socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades

constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias.

Nesse aspecto, por sua propriedade, transcrevo parte da decisão proferida pelo eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO, ex Presidente de nossa honrada Corte de Justiça Bandeirante, nos autos da Revisão Criminal nº 0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de 2014: “A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático”.

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido”.

(negritei)

(STJ - AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na mesma toada, é o posicionamento atual de nossa E. Corte de Justiça Paulista, que abaixo transcrevo, com destaques:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC Nº 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS - FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO - CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL - SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO.”

(Embargos de Declaração Criminal 1506211-61.2019.8.26.0050; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Data do Julgamento: 25/11/2020).

“EMBARGOS INFRINGENTES - Tráfico de drogas - Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido - Parcial acolhimento - Tráfico de drogas privilegiado - Natureza hedionda afastada - Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Não cabimento - Benesse que não se mostra suficiente para

reprovação e prevenção do crime - Regime inicial aberto - Possibilidade - Quantidade compatível à determinação do HC nº 596.603 do C. STJ - Embargos Infringentes parcialmente acolhidos."

(Embargos Infringentes e de Nulidade 0010198-32.2019.8.26.0196; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): ROBERTO PORTO; Data do Julgamento: 24/11/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 - Regime aberto - Possibilidade - Determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603/SP - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso ministerial parcialmente provido."

(Apelação Criminal 1500230-13.2019.8.26.0580; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): RICARDO SALE JÚNIOR; Data do Julgamento: 11/11/2020).

b) WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 50/63) e Certidões carreadas (fls. 64/69), que o réu, além de ser multirreincidente, condição a ser sopesada adiante, ostenta Maus Antecedentes, em virtude de condenação definitiva pelo crime de roubo (Processo nº 0019267-60.2006.8.26.0482 - fls. 64/65).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva da "cocaína" e a significativa quantidade de entorpecente apreendido.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/4 (um quarto), ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (meses) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, como já destacado anteriormente, verifico que o réu é multirreincidente (art. 61, I, CP), haja vista possuir condenação definitiva pretérita pelos crimes de roubo (Processo nº 0024067-58.2011.8.26.0482 - 08/06/2018 Pena cumprida ou julgada extinta (Trânsito MP 18/06/2018, defesa 25/06/2018) - fls. 65/66), por furto qualificado (Processo nº 1500468-23.2019.8.26.0583 - 30/06/2020 Trânsito em Julgado para a Defesa - fls. 66) e pelo delito tipificado no art. 29 da Lei nº 9.605/1998 (Processo nº 1501572-62.2019.8.26.0482 - 18/07/2019 Processo de Execução Iniciado - fls. 66), razão pela qual, agravam-se as penas em 1/4, passando-as para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento capitulada no art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, haja vista o tráfico ter, como bem evidenciado nos autos, ocorrido em transporte público, elevam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 911 (novecentos e onze) dias-multa.

Destaco, ainda, não ser o caso de se aplicar a redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, o réu é multirreincidente e

possui maus antecedentes.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção, assim como, a multirreincidência e os maus antecedentes ostentados.

Afora a natureza hedionda por equiparação do delito de tráfico, por não estarem preenchidos os requisitos subjetivos (multirreincidência e maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR:

a ré ELISABETH SANTOS DE SOUZA, qualificada a fls. 14, nascida aos 18.04.1999, natural de Carapicuíba/SP, filha de Faustino Sergio de Souza e Jane Barbosa dos Santos, RG nº 45.162.639-4 SSP/SP (fls. 42), pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa no valor unitário mínimo legal;

o réu WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES, qualificado a fls. 222, nascido aos 12.04.1987, natural de Vila Velha/ES, filho de Hercules Correia Rodrigues e Jane Barbosa dos Santos, RG nº 45915370, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 911 (novecentos e onze) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Ausentes, à luz do contexto dos autos, especialmente em razão da recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo à condenada ELISABETH o direito de recorrer em liberdade.

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, somado, ainda, aos maus antecedentes e a multirreincidência ostentados pelo condenado, inviável a concessão ao réu WELLINGTON do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Expeça-se, pois, com relação ao réu WELLINGTON, mandado de prisão.

Tratando-se de pessoas desprovidas de recursos, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro e aparelho celular apreendidos (Auto a fls. 12/13 e Guia de depósito a fls. 180) possuem relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento de ambos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Para controle, consigno que o réu Wellington é assistido por Defensor Público, enquanto a ré Elisabeth, por Defensor constituído (fls. 141).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, oficie-se para reversão do dinheiro e aparelho celular à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 03 de novembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA